SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de Protocolo
e Baixa de Processos
28/03/2005 18:09 31730

ADI 3450-2

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com fundamento no artigo 103, inciso VI, da Constituição Federal, vem perante esse egrégio Supremo Tribunal Federal ajuizar AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE do art. 3º da Lei Federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a fim de se lhe excluir a interpretação que permite ao juiz, na fase de investigação criminal, determinar de ofício a interceptação de comunicações telefônicas, por ser esse entendimento conflitante com os artigos 5º, inciso LIV, 129, incisos I e VIII, e §2º, e 144, §1º, incisos I e IV, e §4º, da Carta Magna.

2. Eis o teor do dispositivo que contém a interpretação impugnada:

> *"**Art. 3º** A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:*
> *I – da autoridade policial, na investigação criminal;*
> *II – do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal".*

TRIBUNAL 03

3. Esta inicial é acompanhada de cópia da lei que contém o dispositivo parcialmente impugnado, consoante determina o art. 3º, parágrafo único, do diploma que disciplina a ação direta (Lei nº 9.868/99).

4. A Lei Federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal, dispondo sobre a interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

5. O art. 3º dessa lei permite ao juiz determinar a interceptação telefônica de ofício ou a requerimento da autoridade policial ou do membro do Ministério Público. Tal dispositivo dá ensejo à interpretação segundo a qual o magistrado está autorizado a determinar a interceptação de ofício tanto na fase de investigação criminal quanto na de instrução processual penal. Ocorre que, na fase pré-processual, essa modalidade de interceptação telefônica não encontra respaldo na Constituição da República.

6. Com efeito, a prevalecer o entendimento contrário, restariam maculadas as normas constitucionais concernentes ao devido processo legal e ao sistema acusatório, previstas nos artigos 5º, inciso LIV, 129, incisos I e VIII, e §2º, e 144, §1º, incisos I e IV, e §4º.

7. A iniciativa da interceptação pelo juiz, na fase que antecede a instrução processual penal, ofende o devido processo legal na medida em que compromete o princípio da imparcialidade que lhe é inerente, e vai de encontro ao sistema acusatório porque usurpa a atribuição investigatória do Ministério Público e das Polícias Civis e Federal, permitindo ao julgador a assunção desse mister.

8. Não se quer demonstrar com isso que, durante o curso do processo penal, não vigoram o princípio da imparcialidade e o sistema acusatório. É que, nessa fase, tais postulados devem ser harmonizados com os princípios da verdade real e o do livre convencimento motivado, que também encontram guarida na Lei Maior.

9. Distinguindo a fase pré-processual da processual, para análise da possibilidade da interceptação de ofício, o professor Paulo Rangel preleciona:

> *"... o Juiz não deve conceder de ofício a medida cautelar preparatória, pois esta deverá ser requerida pelo Ministério Público (dominus litis) ou mediante representação da autoridade policial pois, pelo sistema acusatório, adotado entre nós, o Juiz foi afastado da persecução penal. Porém, nada obsta que a medida cautelar incidental (adotada no curso do processo) possa ser deferida pelo Juiz de ofício em nome do princípio da verdade real e de acordo com o sistema do livre convencimento. Pois, se sustentarmos tese contrária, o Juiz não mais poderia decretar medida cautelar pessoal de ofício (prisão preventiva) ou medida cautelar real (busca e apreensão).*
> *Assim, fazemos distinção: no curso do inquérito policial não pode (e não deve) o Juiz decretar a medida de ofício, porém no curso do processo nada obsta que o faça em nome dos postulados acima mencionados" (RANGEL, Paulo. Breves considerações sobre a Lei 9296/96. **Jus Navigandi**, Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=195>. Acesso em: 21 mar. 2005).*

10. No mesmo sentido da impossibilidade de interceptação de ofício na primeira fase da persecução penal, é o entendimento de João Roberto Parizatto (Comentários à lei nº 9.296, de 24-07-96. Leme: Led, 1996, p. 37) e Marcellus Polastri Lima (Ministério Público e persecução criminal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 53).

11. O eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ao pronunciar-se na ADI 1570 - cujo dispositivo questionado era o art. 3º da lei de combate ao crime organizado (Lei nº 9.034/95), que atribuía ao magistrado a realização pessoal de diligência - votou no sentido da supressão dos poderes instrutórios do juiz na fase pré-processual, sem, contudo, elidir eventuais iniciativas suas na instrução. O insigne Ministro Pertence continuou o seu voto afirmando que:

> *"Não estamos perante um juiz absolutamente neutro, pelo menos na nossa versão do processo acusatório, que não é a do puro processo acusatório anglo-saxão, em que se tem, idealmente, o juiz totalmente passivo. De forma que não se afasta a constitucionalidade de iniciativas do juiz de aprofundamento ou complementação da prova no curso do processo, como foram os exemplos aqui citados da inspeção pessoal de pessoas ou coisas".*

05

12. No julgamento proferido na referida ADI 1.570, cuja relatoria ficou a cargo do então Ministro Maurício Corrêa, esse egrégio Supremo Tribunal decidiu, vencido o Ministro Carlos Velloso, pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, na parte não revogada pela Lei Complementar nº 105/01. Os fundamentos dessa veneranda decisão são os mesmos da presente pretensão, motivo pelo qual é oportuno transcrever a ementa do que foi julgado:

> *"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE.* ***"JUIZ DE INSTRUÇÃO". REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL.***
> *1. Lei 9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01. Revogação da disciplina contida na legislação antecedente em relação aos sigilos bancário e financeiro na apuração das ações praticadas por organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto aos procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e informações bancárias e financeiras.*
> ***2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal.***
> ***3. Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e § 2o; e 144, § 1o, I e IV, e § 4o).*** *A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes.*
> *Ação julgada procedente, em parte" (ADI 1570-2, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 22/10/2004 – grifos nossos).*

13. O douto professor Luiz Flávio Gomes, em seu artigo intitulado *Interceptação telefônica "de ofício": inconstitucionalidade*, a despeito de entender que existe a aludida eiva tanto na fase pré-processual quanto na processual, realça, em diversas passagens do seu texto, a mácula na primeira fase da persecução penal:

> *"Dentre as atribuições e competências do juiz, fixadas pela Carta Magna, em nenhum momento vislumbra-se a de tomar a iniciativa*

06

*de provas, **particularmente 'fora' do devido processo legal**. Juiz e devido processo legal são dois conceitos inseparáveis.*
(...)
*É inconstitucional a interceptação telefônica 'de ofício', em conseqüência, porque vulnera o modelo acusatório de processo, processo de partes, instituído pela CF de 1988, quando considera os ofícios da acusação e da defesa como funções essenciais ao exercício da jurisdição, atribuindo esta aos juízes, que têm competência para processar e julgar, mas não para investigar, **principalmente no âmbito extraprocessual**.*
(...)
Tomar a iniciativa da prova 'compromete psicologicamente o juiz em sua imparcialidade'. O juiz não pode ter idéias pré-concebidas sobre o que vai decidir. O legislador pôs em xeque o princípio da ação ou do ne procedat iudex ex officio*" (Revista Jurídica, nº 242, dez/97, p. 33, 35 e 36 – grifos nossos).*

14. Por fim, colhidas as informações necessárias e ouvido o Advogado-Geral da União, requer o Procurador-Geral da República seja-lhe aberta vista dos autos, e julgado, a final, procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º da Lei Federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, como meio para conferir-lhe interpretação conforme a Constituição.

Brasília, 29 de março de 2005.

CLAUDIO FONTELES
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

HUGO LEONARDO IULIANI

Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996.

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6º Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8° , ciente o Ministério Público.

Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Página Anterior